

1500648-51.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 19 porções de cocaína e 56 de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nos termos da denúncia, o réu trazia consigo as mencionadas porções de entorpecentes - em local amplamente conhecido por ser ponto de narcotráfico -, para fins de tráfico ilícito, quando, ao notar a presença de guardas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500648-51.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500648-51.2022.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAMES WILLIAM DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

JAMES WILLIAM DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 08 de junho de 2022, por volta das 15h30min, na Estrada dos Pires, 226, Jardim Suely, em Atibaia, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 19 porções de cocaína e 56 de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nos termos da denúncia, o réu trazia consigo as mencionadas porções de entorpecentes - em local amplamente conhecido por ser ponto de narcotráfico -, para fins de tráfico ilícito, quando, ao notar a presença de guardas que passavam pela via, ficou nervoso, atravessou a rua e começou a correr. Diante de tal atitude suspeita, os guardas foram a seu encalço e viram que durante a fuga - na qual ele pulou o muro de uma residência, um alambrado e atravessou um córrego - JAMES dispensou alguns objetos que estavam em seu bolso.

Conforme constou da exordial, mais adiante, os agentes da Lei conseguiram detê-lo e, em revista pessoal, encontraram consigo duas porções de cocaína e a quantia de R\$ 20,00, bem como um celular. Ademais, recuperaram os itens que haviam sido dispensados pelo réu, verificando que se tratava das demais porções de entorpecentes. Indagado, JAMES admitiu informalmente que estava vendendo drogas

naquela localidade havia um mês, que seu “turno” era das 10h às 22h. Revelou também que fazia cerca de quatro meses que havia sido posto em liberdade, pois estava recolhido em estabelecimento prisional.

Réu preso em flagrante, sendo sua prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia (fls. 54/56). A denúncia foi oferecida (fls. 72/73), o réu foi notificado (fls. 90) e apresentou defesa preliminar (fls. 97/98), que foi afastada, sendo recebida a denúncia (fls. 103/106). O réu foi citado (fls. 118). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo o réu interrogado ao final (fls. 119/120).

Em memoriais, a representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia (fls. 133/138).

A defesa apontou que o réu, em audiência, negou a prática do crime, que os policiais ouvidos informaram que no momento do flagrante, encontraram com o réu duas porções de cocaína, R\$ 20,00 e um celular, sendo que não viram o réu entregando ou vendendo drogas e que o laudo definitivo do exame da substância apreendida não havia sido juntado até a data da audiência. Alegou que o laudo de exame toxicológico definitivo deve anteceder a audiência de instrução e julgamento e que o laudo de constatação provisório de entorpecentes foi realizado pelos próprios policiais que elaboraram os documentos da prisão em flagrante, sendo que a Lei 11.343/06 estabelece que o documento deve ser redigido por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea. Requereu a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, alegando inexistência de materialidade e, caso não seja esse o entendimento, desclassificação da conduta pela qual o réu foi denunciado para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Tóxicos (fls. 166/169).

É o relatório.

Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 03), no auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 13/14), no boletim de ocorrência (fls. 17/19), nas fotografias dos entorpecentes apreendidos (fls. 40/41), nos laudos periciais de exames químico-toxicológicos (fls. 124/125 e 127/128) e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada ao réu que, interrogado extrajudicialmente, negou a prática do tráfico de drogas; disse que foi detido num estabelecimento, onde foi revistado e nada foi encontrado em seu poder; admitiu ter corrido ao ver a viatura porque se assustou, pois saiu recentemente do estabelecimento prisional, informando ter cumprido cinco anos e sete meses por crime de roubo; negou ter jogado drogas enquanto corria, afirmando que as drogas que os policiais acharam estavam no mato e não lhe pertenciam, repetindo que em sua posse nada foi encontrado; não conhece os guardas municipais, já que está morando em Atibaia há pouco tempo (fls. 09).

Em juízo, o réu afirmou que nada foi encontrado em seu poder; indagado sobre o motivo pelo qual está sendo acusado, respondeu que foram encontrados dois papérols de cocaína em seu poder, além de R\$ 20,00, um celular e um relógio; o restante do entorpecente foi encontrado por cachorro, no mato, em outro lado da via em que eles estavam ao vê-lo; indagado sobre o motivo pelo qual os policiais disseram que lhe viram dispensando a droga, respondeu que quando correu, tinha apenas R\$ 20,00 e dois papérols; indagado sobre de onde surgiu a droga, se não era sua, respondeu que o cachorro que encontrou, num terreno baldio, do outro lado da rua; trabalhava com banners e adesivos, auferindo R\$ 50,00 por dia na Publicolors, em Bragança Paulista; no dia em questão estava visitando sua avó na Estrada Velha de Bragança Paulista e decidiu comprar dois pinos de cocaína; indagado sobre o motivo pelo qual não estava trabalhando no dia, respondeu que estava de folga no dia; já foi processado por roubo e furto; cumpriu sua pena; confirmou ter corrido e entrado numa “firma”; o policial Erik, ao lhe capturar, pediu para que todos saíssem da “firma”; os agentes não queriam lhe prender, sendo que queriam lhe arrastar para o mato para matá-lo; Erik pediu para Rubens buscar o “38” dentro do carro; começou a

gritar e um monte de gente da “firma” começou a chegar e a perguntar o que estava acontecendo; foi colocado na viatura e levado até o local em que estava o cachorro, no terreno baldio, onde foi encontradas as 19 porções; Rubens lhe indagou se queria conversar, tendo respondido que não tinha nada consigo; Rubens, então, lhe pediu R\$ 5 mil para liberá-lo; como disse não ter o dinheiro, foi levado para a Delegacia; indagado sobre o motivo pelo qual queriam matá-lo, respondeu não saber.

A testemunha Erik Tadeu de Oliveira, guarda municipal, disse que estavam em patrulhamento pelo Bairro do Tanque, quando pela Estrada Velha de Bragança Paulista, avistaram um indivíduo em sentido oposto ao da viatura; referido indivíduo, ao perceber a presença da viatura, parou e teve mudança repentina de percurso, atravessando a via; antes de ser dada voz de parada, o indivíduo empreendeu fuga, pulando o muro de uma residência e um alambrado, caindo num córrego; acompanharam o réu e o detiveram numa fábrica de tubos; durante o trajeto, o réu levava a mão ao bolso e dispensava objetos ao solo; ao serem recolhidos, verificaram que se tratava de porções de cocaína e pedras de crack; durante a abordagem, o réu tinha em seu bolso duas porções de cocaína, a quantia de R\$ 20,00 e um celular; indagado, o réu confessou a prática da traficância na localidade, informou que havia saído do sistema prisional há cerca de quatro meses e que em torno de um mês estava trabalhando naquela “biqueira”, sendo que seu turno era das 10h às 22h; não conhecia o réu de outras abordagens; indagado pela acusação se as porções que estavam em poder do réu estavam embaladas da mesma forma que as porções encontradas no caminho, respondeu que sim, eram idênticas, se tratando das porções conhecidas por “Aricanduva”.

A testemunha Rubens Augusto Domingues, também guarda municipal, disse que durante operação no Bairro do Tanque, em locais que sabem ocorrer tráfico de entorpecentes, por ocasião do patrulhamento, viram um indivíduo que, ao perceber a viatura, antes mesmo que pudessem proceder à abordagem, desviou o caminho e saiu correndo; o indivíduo adentrou uma residência e foi pulando por vários locais, até chegar num córrego; chegando ao córrego, o indivíduo começou a dispensar algumas coisas que estavam no bolso dele; conseguiram cercá-lo numa casa de materiais; voltaram e recolheram os itens que ele havia dispensado; em busca pessoal, encontraram duas porções de cocaína com o acusado; no caminho feito pelo réu, encontraram outras porções de cocaína, do mesmo tipo daquelas encontradas com o acusado, prontas para a venda, além de uma embalagem com tubos de crack; o réu confessou que estava fazendo o tráfico no local, tendo informado que havia saído da cadeia há quatro meses, sendo que estava traficando há cerca de um mês; não conhecia o réu de outras abordagens; pela defesa foi indagado se o réu dispensou as drogas enquanto corria, ou se as dispensou dentro do córrego, respondeu que ele dispensou durante o trajeto, mais próximo do córrego; recolheram a quantidade que encontraram, sendo que as porções estavam secas.

Pois bem.

O réu negou a prática delitiva, afirmando, em solo policial, que foi detido num estabelecimento e, após revista, nada foi encontrado em seu poder. Alegou ter corrido da viatura por ter saído recentemente de estabelecimento prisional. Negou ter arremessado as drogas enquanto corria, dizendo que as drogas encontradas pelos policiais estavam no mato e não lhe pertenciam.

Em juízo, optou por incrementar a versão exculpatória: além de voltar a negar qualquer relação com a droga apreendida, afirmou que em seu poder foram encontrados apenas dois papелotes de cocaína, R\$ 20,00, um celular e um relógio, que estava visitando sua avó e decidiu comprar dois pinos de cocaína e que os agentes que o detiveram queriam, em verdade, matá-lo. Contraditoriamente, entretanto, alegou que um dos agentes chegou a lhe pedir R\$ 5 mil para liberá-lo (embora momentos antes tenha alegado que os agentes queriam matá-lo), mas como não tinha dinheiro, levaram-no para a Delegacia. Indagado, não soube dizer por qual motivo os guardas municipais queriam matá-lo.

Voltou a afirmar que o restante do entorpecente foi encontrado no mato, por cachorro e, ao ser indagado sobre o fato de os agentes terem visto o momento em que dispensou a droga, voltou a afirmar que quando correu, tinha apenas R\$ 20,00 e dois papелotes de cocaína.

Como se nota, as insubsistentes narrativas do réu, além de díspares, carecem de comprovação, sendo certo que o acusado não comprovou quaisquer de suas alegações. Apenas negou ser o proprietário do entorpecente que foi visto dispensando, criando, ainda, fantasiosa versão de que os agentes queriam ora matá-lo, ora extorqui-lo. O réu sequer se deu ao trabalho de tentar justificar a razão pela qual os agentes teriam interesse em ceifar sua vida, sendo certo que em solo policial afirmou não conhecer os guardas, já que estava morando em Atibaia há pouco tempo.

Em posição diametralmente oposta, a prova formada pela acusação foi plenamente apta a demonstrar que o réu praticava o tráfico de entorpecentes.

Neste sentido, as testemunhas guardas municipais relataram que estavam em patrulhamento e avistaram um indivíduo em sentido oposto ao da viatura, que ao notar a presença da Guarda Municipal, mudou de curso repentinamente, empreendendo fuga, pulando o muro de uma residência e um alambrado, caindo num córrego em seguida.

Os agentes relataram que detiveram o réu numa fábrica e confirmaram que viram, durante o trajeto, o acusado dispensar objetos ao solo, os quais recolhidos, revelaram-se se tratar de porções de cocaína e pedras de crack.

Além disso, os guardas ouvidos confirmaram que durante a abordagem, encontraram com o réu duas porções de cocaína, embaladas de forma idêntica àquelas por ele dispensada anteriormente, e a quantia de R\$ 20,00 e um celular.

Os agentes relataram, por fim, que o réu confessou informalmente a prática da traficância, informou que havia saído do sistema prisional há cerca de quatro meses e que estava trabalhando naquela “biqueira” havia cerca de um mês, sendo que seu turno era das 10h às 22h.

Assim, a prova formada deu conta de que o réu, em local afamado pela prática do tráfico, fugiu de viatura da Guarda Municipal assim que a avistou, sendo que durante o trajeto dispensou diversas porções de entorpecentes, sendo detido, em seguida, em poder de duas porções de cocaína (embaladas de forma idêntica àquelas que dispensou), além de R\$ 20,00 em dinheiro e um celular.

Indagado pelos guardas, no momento da abordagem, confessou informalmente a prática do tráfico, relatando, inclusive, seu turno de “ofício”. Em seus interrogatórios, entretanto, apresentou relatos insubsistentes e não lineares, tornando sua lânguida versão absolutamente isolada no feito, diferentemente da prova produzida a partir do depoimento dos guardas municipais ouvidos.

É conveniente rememorar que os depoimentos judiciais de guardas municipais e policiais, sejam civis ou militares, têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo descabido eventual preconceito acerca de seus testemunhos.

Inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por guardas municipais ou policiais, sejam civis ou militares, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Inexiste, ainda, qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de guardas municipais e policiais, civis ou militares, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retire valor, a priori, dos depoimentos dos agentes da Lei, pelo simples fato de emanarem de pessoas revestidas de tal qualidade.

Neste sentido:

“APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. REGIME SEMIABERTO PARA O CRIME DE DESACATO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 2. Depoimentos dos guardas municipais harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal do réu. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF

e do STJ. 3. Em uma atuação secundária, cabe aos guardas municipais a preservação da ordem pública, a qual é responsabilidade de todos, sendo imposta aos órgãos de segurança o dever legal. Desta forma, é conferida à guarda municipal a possibilidade de prender quem estiver em flagrante delito, bem como recolher todos os instrumentos utilizados na prática da infração penal, a fim de que melhor subsidie a apuração dos fatos, nisto incluída a revista pessoal. Precedentes do STJ (...)” (TJ-SP - APL: 00059693020128260372 SP 0005969-30.2012.8.26.0372, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 26/02/2015, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 05/03/2015).

Nem se diga, ainda, existir ilegalidade na ação empreendida pelos Guardas Municipais por ocasião dos fatos, seja em relação à busca pessoal ou mesmo à condução do acusado à Delegacia de Polícia.

Consoante entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, não há óbice à realização de tal tarefa, incluindo-se a prisão, pelos mencionados servidores públicos, ainda que tal carreira não conste, de forma expressa, do rol constante do art. 144, da Constituição Federal. Trata-se, pois, de faculdade conferida a qualquer povo, além de representar um ato que objetiva a proteção da segurança social.

Assim já se decidiu:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não tem o condão de inquinar de nulidade a ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítima a sentença condenatória. 4. Ordem denegada”. (STJ - HC: 129932 SP 2009/0035533-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 15/12/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2010).

E ainda:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDAS MUNICIPAIS. ABUSO DE AUTORIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Não há falar em ilegalidade de prisão em flagrante, porque efetuada por guardas municipais de trânsito, se pode fazê-lo qualquer do povo (artigo 301 do Código de Processo Penal). 2. Recurso improvido”. (STJ - RHC: 14585 SP 2003/0102527-9, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Publicação: DJe 08/08/2005).

Mesmo que assim não fosse, não há que se falar, tecnicamente, em nulidade na fase de inquérito, mas apenas eventual irregularidade, condição esta que não tem o condão de contaminar ou viciar a ação penal que lhe sucedeu.

Os laudos periciais de fls. 124/125 e 127/128 foram aptos a indicar a apreensão, pela Guarda Municipal, de substância psicotrópica de uso proscriito no Brasil, qual seja, a cocaína.

Convém rememorar que o crack é produzido a partir dos restos do refino da cocaína, que, por sua vez, é produzida a partir de uma pasta-base. O crack, portanto, não é substância autônoma, mas sim subproduto da cocaína. Logo, é certo que o laudo de exame químico-toxicológico, ao analisar o crack, atestará a presença de cocaína. Em suma, a prova oral formada a partir do coeso depoimento das testemunhas, as drogas encontradas tanto com o réu, quanto pelo caminho que ele fez enquanto empreendia fuga (as quais estavam embaladas de forma idêntica) e as versões inconsistentes apresentadas pelo réu para a ocorrência como um todo, ou seja, o flagrante em sua totalidade, realizado em local conhecido pela prática de traficância, são circunstâncias que trazem a certeza necessária para o decreto condenatório pelo delito previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06, não havendo que se falar em improcedência da ação por não haver provas para sua condenação. Nem se diga, ainda, que o réu se tratava de mero usuário de entorpecentes. É importante, sobre a questão, destacar que o artigo 33 da Lei 11.343/06 não define

como necessário, para a consumação das figuras típicas em questão, o caráter comercial do tráfico. Aliás, sequer delimita qualquer definição para “traficante”, limitando-se a descrever figuras típicas que, praticadas, ensejam penalidade. In verbis:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa” (Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006).

Optei por destacar, na transcrição acima, justamente a conduta descrita na denúncia, a qual foi perpetrada pelo réu, bem como o restante do dispositivo, restando evidenciado que não há, na Lei, qualquer menção sobre a necessidade de se evidenciar a finalidade mercantil do entorpecente.

Já a ação descrita no artigo 28 da Lei 11.343/06 dispõe que “Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)” (destaquei e grifei), estará sujeito às sanções previstas naquele dispositivo.

Este artigo, sim, aponta uma finalidade específica: o consumo pessoal. Assim, a comprovação de que a droga era destinada ao consumo pessoal cabe àquele que assim alega, conforme a regra estampada no artigo 156 do Código de Processo Penal. O réu não se desincumbiu de tal ônus, não tendo formado mínima prova a respeito de eventual consumo de entorpecentes.

Não há, assim, como sustentar que o réu se tratava de mero usuário, o que impede a desclassificação postulada.

Nada há que se argumentar, também, a respeito do laudo pericial ter sido juntado após a audiência de instrução. A defesa técnica teve acesso aos laudos antes da apresentação dos memoriais e, assim, restou garantida a ampla defesa e o contraditório, razão pela qual não houve qualquer prejuízo à defesa do acusado. Por fim, nada há que se observar a respeito do laudo de constatação provisório de entorpecentes, que foi subscrito por pessoas idôneas, da forma que determina a Lei, não tendo havido, de igual forma, qualquer prejuízo à defesa do réu.

Destarte, é caso de procedência da ação.

Reconhecida a autoria, passo a dosar a pena.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal. No entanto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu ostenta três condenações pretéritas ensejadoras de reincidência, de modo que uma lhe onerará como maus antecedentes e as demais, como reincidência propriamente dita. Desta forma, utilizo a condenação estampada na certidão de fls. 43, referente ao processo 0000056-91.2016.8.26.0545, cuja sentença transitou em julgado para a defesa em 25 de maio de 2018 como forma de reconhecer-lhe maus antecedentes.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. MESMA CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSIDERADA DUAS VEZES. FASES DISTINTAS DE APLICAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. JUÍZO NEGATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. (...) 4. É pacífica a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que, a existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis, autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo. 5. Este Sodalício orienta que não configura bis in idem ou inconstitucionalidade, quando, reconhecidas múltiplas reincidências, o sopesamento, na fixação da condenação, de uma na primeira fase, para exasperar a pena-base pelos maus antecedentes (art. 59, CP), e de outra na segunda fase, como circunstância agravante (art. 63, CP) (...)" (STJ - HC: 215126 MS 2011/0183443-9, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2013) (destaquei).

No mais, culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar. Pouco se colheu a respeito de sua conduta social e personalidade. Quanto aos motivos do crime, os comuns ao tráfico. Quanto à natureza e quantidade do produto, foram apreendidas 19 porções de cocaína e 56 de crack. A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendida é razão suficiente para que a conduta seja exemplarmente repreendida (artigo 42, Lei 11.343/06).

Sobre o tema, pronunciou-se Guilherme de Souza Nucci: "(...) não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos também constantes do art. 59 do Código Penal (...) A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que significa destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização" (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas 6ª ed. - São Paulo: RT 2012 v. 1 p. 287).

Assim, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis apontadas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão, e 600 dias-multa, diária mínima, uma vez que o réu está preso. O valor total da pena de multa deverá ser atualizado nos termos do art. 49, §2º, do Código Penal.

Na segunda fase de dosimetria, incide a agravante relativa à reincidência (artigo 61, I, do Código Penal). O réu é reincidente, haja vista as condenações estampadas na certidão de fls. 44/45 dos autos, referente aos processos nº 0002344-50.2017.8.26.0521, cuja pena foi considerada cumprida em 29 de junho de 2017 - não tendo decorrido o prazo depurador de cinco anos entre tal condenação e o novo delito - e nº 6482-02.2016.8.26.0099, condenação cujo trânsito em julgado ocorreu em 17 de julho de 2018. A pena é agravada, e atinge o patamar de 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, além de 720 dias-multa. Não incidem atenuantes.

Na terceira e última fase da dosimetria penal, não há causas de aumento de pena. Considero incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. O réu é multirreincidente, o que impede objetivamente a concessão do benefício.

Destarte, a pena definitiva é fixada em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, além de 720 dias-multa.

O regime inicial para cumprimento de pena será o fechado, considerando o fato de que se trata de réu reincidente, que ostenta circunstâncias judiciais absolutamente desfavoráveis.

Além disto, de se considerar que o tráfico de entorpecentes é das atividades mais danosas ante o seio social hodierno. Sua prática atinge diretamente direitos e garantias fundamentais das pessoas, além de fomentar outros tipos de atividades ilícitas. Causa, ainda, direta e indiretamente, considerável mobilização estatal, atingindo, por consequência, o erário público, que tem de arcar com as custas de policiamento ostensivo, seja preventivo ou repressivo, campanhas de conscientização - sobre o óbvio, diga-se -, tratamento de saúde aos adeptos do uso contumaz, dentre outras inúmeras situações relacionadas, as quais requerem pronta ação do Estado. Isto, entretanto, custa dinheiro e onera o contribuinte.

Seria um contrassenso o mesmo Estado que luta para combater tão nefasta prática - a tão altos custos - permitir que seu principal responsável retorne à liberdade sem experimentar a necessária punição e, principalmente, sem que de seu ato se

arrependa, sobre ele reflita e o corrija, podendo criar, em última análise, a aplicação de regime mais brando, verdadeira sensação de impunidade, capaz, inclusive, de ensejar ao condenado mais um motivo para que torne à rentável prática.

Nem se diga haver o pequeno traficante, sobre quem recairia todo o peso da mão Estatal, e o grande traficante, que se ocultaria na hierarquia da coalizão narcotraficante, como tentativa de justificar atos injustificáveis. A Lei coíbe o tráfico e este existe por duas razões: porque alguém consome o produto e porque alguém o vende – eis a figura daquele que trafica, independentemente de sua posição hierárquica.

A ação do indivíduo encarregado de disseminar a substância entorpecente – geralmente identificado como o “pequeno traficante” – deve ser entendida como parte integrante e crucial do conjunto responsável pela narcotraficância: é ele que, por meio de sua ação, viabiliza o comércio “varejista” das drogas, fomentando o consumo e a própria continuidade da produção de entorpecentes, consubstanciando, sua atividade, não só o meio de sustento próprio, mas de toda a cadeia criminosa ligada ao narcotráfico – prática delitiva que domina a maior parte dos debates sobre segurança pública e que consiste, em verdade, no cerne financeiro das atividades criminosas em geral.

É do espírito da Lei combater o tráfico ilícito de entorpecentes, seja ele praticado pelo iniciante – a quem é conferido algum tipo de benefício, conforme se observa do parágrafo 4º do artigo 33, Lei 11.343/06 – pelo gerente de “boca” ou por associados a organizações criminosas – pessoas a quem a Lei trata de maneira especial e mais severa.

O fato é que o tráfico, independentemente do tipo de atuação de seu praticante, merece reprimenda exemplar.

Sobre todo o tema até então debatido, uma brilhante manifestação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“(…) Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e a recente decisão da Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de direitos” constantes dos artigos 33, § 4º e 44 da Lei Antidrogas. Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na decisão é ressaltada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição. Tal como veiculado de forma contínua nos diários de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal. Evidentemente o grande traficante, o responsável pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de necessidades básicas. Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O número expressivo de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas, bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena



por quaisquer das medidas alternativas. Portanto, acolho a pretensão do representante do Ministério Público e fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista que se trata do regime compatível com a conduta do acusado. Cumpre ressaltar ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um revés de complexidade. Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal? Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante? A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante. Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas. E a consequência desta fartura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua sobrevivência. Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano. Devo reconhecer que tenho sido voto vencido junto a meus pares, a cujos posicionamentos me curvo com a humildade esperada, e por isso mesmo, eventualmente, sou reconhecido como extremamente rigoroso, entretanto, não o faço como castigo, o que seria de todo despropositado e bem acarretaria o desvirtuamento da finalidade da pena. É imperativo ressaltar também que não tenho a menor intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes - como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na Lei nº 11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria visualizar a figura do pequeno traficante. (...)" (APL TJ-SP 0027320-18.2012.8.26.0224; Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Publicação: 18/01/2017; Julgamento: 14 de Dezembro de 2016; Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro).

Salutar a fundamentação, que reduz a termo o espírito buscado pela construção normativa do Legislador. É razão mais que suficiente para que se entenda que o praticante do tráfico de drogas deve permanecer afastado do convívio em sociedade. Ficam vedados, ainda, pelas mesmas razões, quaisquer outros benefícios, incluindo-se a substituição da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelas razões acima apontadas, tudo a indicar não ser referida conversão medida adequada e suficiente ao caso concreto.

Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno JAMES WILLIAM DA SILVA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de

07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 720 dias-multa, diária mínima, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

O réu está preso e assim deverá permanecer, já que foi preso em flagrante e permaneceu recolhido por todo o processo, não sendo razoável, agora que foi condenado, ser colocado em liberdade, ainda mais diante do fato de ter praticado conduta de extrema gravidade, nos termos acima fundamentados. A prática exige punição exemplar. Ademais, é réu reincidente, não havendo qualquer segurança ao juízo de que, uma vez em liberdade, não acabe retomando a atividade que ensejou seu encarceramento. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Decreto a perda, em favor do FUNAD, do valor em dinheiro apreendido nos autos, uma vez não comprovada a sua origem lícita. Após o trânsito em julgado, oficie-se para levantamento.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada eventual gratuidade da Justiça.

P.I.C.

Atibaia, 20 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA